

1503781-46.2021.8.26.0510

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Enrique Leandro Barbosa

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

LUIZ ENRIQUE LEANDRO BARBOSA, qualificado nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1503781-46.2021.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503781-46.2021.8.26.0510 - 2021/000791

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Enrique Leandro Barbosa

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

LUIZ ENRIQUE LEANDRO BARBOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 01 de dezembro de 2.021, por volta das 16:40 horas, na Rua 8, nº 557, Parque São Jorge, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 56 (cinquenta e seis) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, e ainda guardava e tinha em depósito outros 118 (cento e dezoito) microtubos do tipo eppendorf contendo a mesma substância entorpecente, totalizando com aqueles outros peso líquido aproximado de 41,7 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo de constatação de fls. 15/17, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 07 de março de 2022.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, inviabilizando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da dedicação criminosa, devendo ser a pena cominada ser cumprida em regime prisional inicial fechado, com imposição, ademais, da pena de perdimento dos valores apreendidos.

Já a ilustre Defensora Pública, sustentando insuficiente a prova produzida, requereu a absolvição do acusado, nos termos do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito irrogado para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade, incidindo a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto, comunicando-se, por fim, à Corregedoria da Polícia Militar sobre eventual abuso da ação policial, nos termos do que exposto pelo acusado.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo e ainda guardava e tinha em depósito o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 50/51, com resultado positivo para cocaína.

Controverte-se sobre a posse da totalidade do entorpecente apreendido, bem como sobre sua destinação mercantil.

Ouvido em Juízo, o acusado afirmou que na ocasião dos fatos estava no local onde abordado, tão somente para adquirir entorpecente, por isto que consigo localizadas apenas duas porções de cocaína, as quais adquiriu de um menor que acabou sendo dispensado pelos Policiais Militares, que realizaram sua prisão em flagrante.

Esclareceu que já estava se afastando do local, tendo observado que tinha apenas adquirido o entorpecente, mesmo assim disse ter sido agredido com um soco no rosto, por isto que empreendeu fuga, atirando realmente pedras contra a guarnição policial. Acrescentou, por fim, que o entorpecente exibido à d. Autoridade Policial estava com outros Policiais Militares que chegaram ao local, não decorrendo de busca realizada por cães de faro, ressaltando que o dinheiro, igualmente apreendido, estava em poder do menor que lhe vendeu o entorpecente.

Todavia, a versão deduzida pelo acusado foi contrariada pela prova produzida.

De fato, os Policiais Militares ouvidos em juízo, reiterando o que exposto contemporaneamente aos fatos, afirmaram que na ocasião estavam em patrulhamento

pelo local dos fatos, já bastante conhecido como ponto de venda de entorpecente, quando avistaram o acusado, acompanhado de um outro indivíduo, mantendo contato com um motociclista. Quando se aproximaram, este último se afastou e foram os dois primeiros abordados. Durante a abordagem, notaram que o acusado tinha algumas porções de entorpecentes nas mãos, tendo reagido e, mesmo com a tentativa de contê-lo, conseguiu fugir, durante a fuga atirando pedra contra a guarnição. Diante do ocorrido, o indivíduo que também fora contido acabou também empreendendo fuga, tendo sido solicitado apoio, que resultou na posterior abordagem do acusado, que estava segurando vinte e seis porções de cocaína, tendo sob as vestes um embrulho contendo outras trinta porções da mesma substância entorpecente, todas contidas em eppendorfs. Em seguida, com o auxílio de cão de faro, que veio com o apoio, localizaram no ponto onde inicialmente abordado o acusado uma embalagem contendo cento e dezoito outras porções de cocaína, também contidas em eppendorfs de cor azul, além da quantia aproximada de dois mil reais, seguindo-se a condução do acusado ao plantão policial.

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais militares envolvidos nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Ademais, cumpre observar que o acusado na ocasião dos fatos se encontrava em gozo de liberdade provisória concedida por ocasião de prisão em flagrante poucos meses antes pela prática de igual delito (1503210.75.2021.8.26.0510), também com significativa quantidade de entorpecente, registrando ele ainda infração equiparada, ainda quando menor (1501532-59.2020.8.26.0510), além de imputação de roubo e furto (1501249-02.2021.8.26.0510 e 1509745-54.2020.8.26.0510).

Deste modo, à míngua de qualquer elemento probatório que amparasse o alegado pelo acusado, neste ponto lhe competindo o ônus da prova, e considerando a apreensão, em poder dele, em ponto de tráfico, de quantidade expressiva de entorpecente, além de quantia aproximada de dois mil reais, em gozo que estava de liberdade provisória onde se lhe imputa a prática de igual delito, que já registrara enquanto menor, circunstâncias que descredenciam o que alegado por ele, têm-se a formação de seguro juízo de convicção sobre a realidade da imputação inicial.

Por fim, considerando que os valores apreendidos estavam embalados com o entorpecente, igualmente possível concluir que decorrentes da atividade criminosa, incidindo, portanto, a pena de perdimento.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, possível seja a pena-base

fixada no mínimo legal, de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Deixo de reconhecer a circunstância atenuante da menoridade, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

E não se mostra possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. É que conta o acusado com o envolvimento reiterado na disseminação de entorpecente, além da prática de outro delito, revelando dedicação criminosa, não obstante a menoridade, não se tratando de nenhum "neófito" que fizesse jus ao chamado "tráfico privilegiado", além de ter sido apreendida com ele quantidade significativa de entorpecentes, como também a quantia de aproximadamente dois mil reais, ambos indicando a intensidade com que realizava o comércio ilícito.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado LUIZ ENRIQUE LEANDRO BARBOSA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, e considerando a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, proferida do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênua, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênua, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se tem por interditada a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descurar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional

inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória.

Sobre isto: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.). Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA